



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 74/15

בענין: חלילי סמירה

ע"י ב"כ עו"ד וליד אבו אל-ניל
ת.ד. 4606, מיקוד 31041

טל': 054-4234234, פקס: 077-5155654

התובעת

נ ג ד

סאבא עאוני

ע"י ב"כ עו"ד גסאן חורי
שפאא – שיח עבאס ו/או רביע חורי

מרח' הבנקים 4 חיפה ת.ד. 33143

טל': 04-8507760, פקס: 04-8507740

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

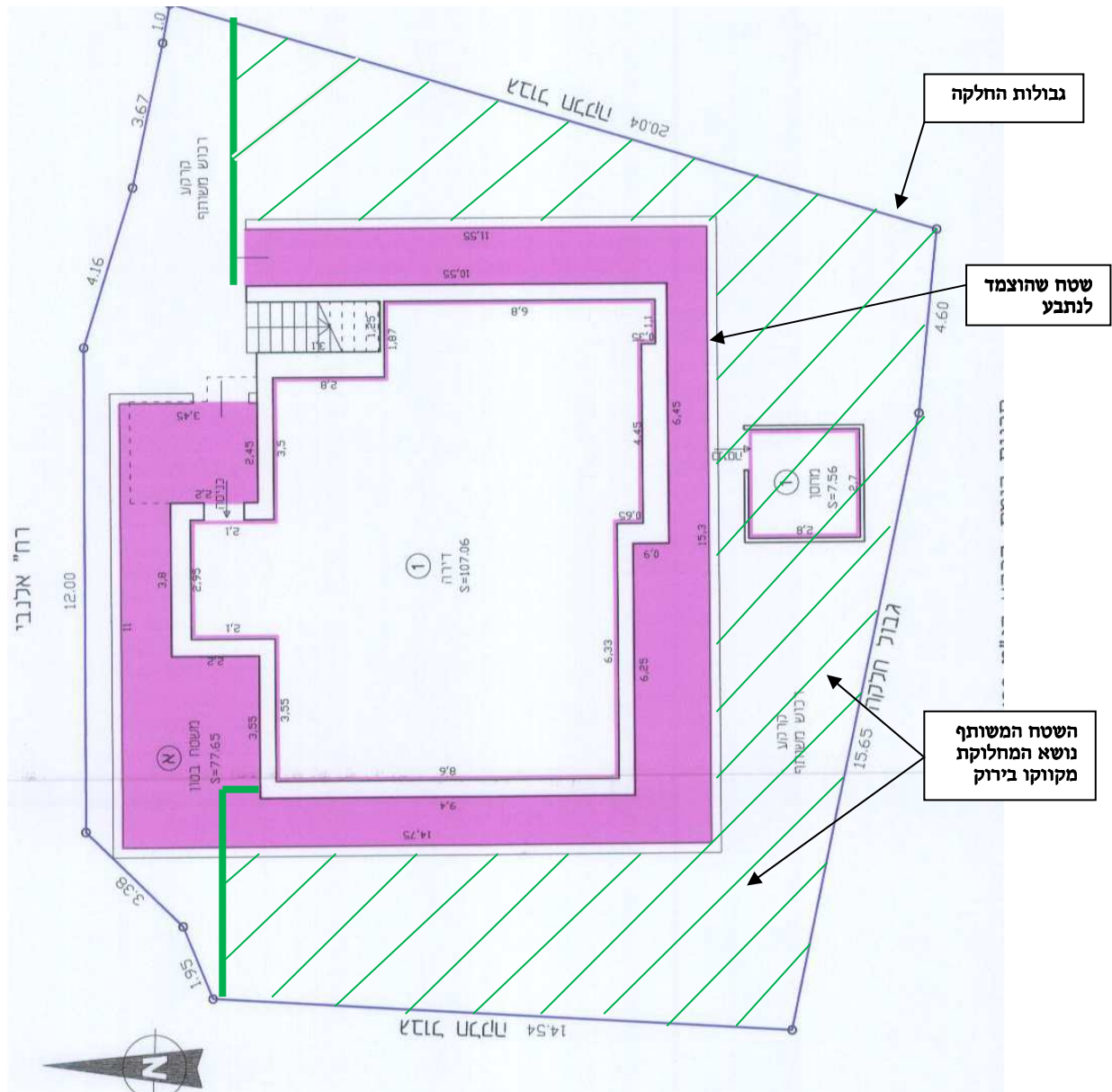
1. עניינה של התביעה, עתירתה של התובעת למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבע לסלק ידו מהרכוש המשותף הכולל את הקרקע והחצר סביב המבנה, ולהחזיר את המצב לקדמותו; להרוס את כל מה שהקים או בנה ברכוש המשותף ללא הסכמתה של התובעת. עוד עתרה התובעת לפירוק שיתוף בחצר המשותפת באופן שהקרקע תחולק בין הצדדים להליך, תוצמד להם וההצמדה תירשם בלשכת רישום המקרקעין.

2. הבית המשותף נושא ההליך נמצא ברחוב אלנבי 63, חיפה, ומזוהה כחלקה 2 בגוש 11676 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

העובדות הצריכות לעניין-

3. ביום 21.6.07 נרשם הבית כבית משותף בן 2 דירות: חלקת משנה מס' 1- דירה בבעלות הנתבע אשר צמודים לה משטח בטון בשטח 77.65 מ"ר המסומן באות א', גג פח בשטח 8.70 המסומן באות ב' וגג רעפים בשטח 7.98 מ"ר המסומן באות ג'. חלקת משנה מס' 2- דירה בבעלות התובעת אשר צמודים לה חדר מדרגות בשטח של 5.88 מ"ר המסומן באות ד', גג רעפים בשטח של 16.24 מ"ר המסומן באות ה' וגג בשטח 96.73 מ"ר המסומן באות ו'.

4. ביום 15.12.11 נרשמה הערת אזהרה על בעלות התובעת לטובת בנה, חיטאב חלילי (להלן: "חלילי") על פי יפויי כוח בלתי חוזר ותצהיר העברה ללא תמורה.
5. ביום 10.3.12 חתמו הנתבע וחלילי על הסכם בו מצהיר חלילי כי רכש את גג הבית המשותף וכי הוא מתכוון לבנות עליו. בהסכם נקבע כי תנאי לביצוע עבודות הבנייה של חלילי הוא ויתורו של חלילי על כל השטח המשותף מסביב לבית לטובת הנתבע (להלן: "ההסכם"). להסכם צורף תשריט, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם, בו סומן השטח עליו מוותר חלילי. ההסכם והתשריט נחתמו ע"י הנתבע וע"י חלילי בנוכחות עו"ד יוסף שלש.
6. בעקבות החתימה על ההסכם הסיר הנתבע את התנגדותו לבניית חלילי דירה על גג הבית וביום 15.5.12 קיבל חלילי היתר בניה והחל בבניית הדירה על גג הבית.
7. התובעת משכנה את דירתה, חלקת משנה מס' 2, במשכנתה בגין הלוואה שנטל חלילי לצורך בניית דירה על הגג.
8. ביום 12.9.13 בוטלה ונמחקה הערת האזהרה שהייתה רשומה לטובת חלילי מנסח הרישום.
9. ביום 3.9.14, לאחר שחלילי השלים את בניית הדירה הנוספת לעצמו, שלחה התובעת מכתב לנתבע בו ציינה כי ההסכם שנחתם בינו לבין בנה חלילי חסר כל תוקף משפטי, מהטעם שחלילי אינו בעל זכויות רשום בספרי המקרקעין, ואינו רשאי לחתום על הסכם או כל מסמך או התחייבות בשם התובעת. משכך, התבקש הנתבע לסלק ידו מהרכוש המשותף עליו השתלט. מכתב דומה שלחה התובעת לנתבע ביום 20.10.14.
10. עד כאן העובדות שאינן שנויות במחלוקת.
11. טרם שאסקור את טענות הצדדים, מצאתי למזג בפסק דיני חלק מתשריט רישום הבית המשותף. על גבי התשריט הוספו הערותיי וסימונים נוספים אחרים שלא לפי כללי המדידה התקינים. ההוספות נעשה אך לשם הבהרה והמחשת הנטען.



טענות התביעה-

12. מדובר במקרקעין מוסדרים בהם הרישום מהווה ראייה חלוטה לתוכנו. יפויי הכוח שנתנה התובעת לחילי נועד לאפשר לו להעביר רק את הגג לבעלותו, וזאת על מנת שינצל את זכויות הבניה ויבנה לו דירה על הגג. התובעת הייתה ונותרה בעלת הזכויות הבלעדית בחלקת משנה מס' 2 ומשכך היא ורק היא רשאית הייתה ליתן הסכמה לנתבע לעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף. חתימתו של חילי על ההסכם הייתה שלא כדין, היא נעדרת תוקף משפטי וחוקי ונעשתה ללא הרשאה בכתב, משכך יש לראות את ההסכם כבטל ומבוטל, אין הוא יכול לחייב את התובעת והפועל היוצא הוא שיש להורות לנתבע לסלק ידו מהרכוש המשותף.

13. ייפוי הכוח עליו חתמה התובעת וכן תצהיר העברה ללא תמורה שנלווה לו מפרטים מפורשות כי ההרשאה שנתנה התובעת היא להעביר את זכויותיה בגג בלבד.

14. הערת אזהרה שנרשמה לטובת חלילי לא אפשרה לו להתחייב בשם אמו התובעת או לוותר על זכויותיה הקנייניות.

טענות ההגנה-

15. חלילי ואמו התובעת חברו יחדיו במהלך מתוכם ומתוכנן היטב שיזם חלילי על מנת להונות את הנתבע.

16. התובעת העבירה בהעברה ללא תמורה לבנה (חלילי) את זכויותיה בדירה, תת חלקה מס' 2, בגין עסקת מתנה זו נרשמה הערת אזהרה, והתובעת נתנה יפוי כוח בידי בא כוחה לבצע את רצונה זה.

17. הנתבע וחלילי ניהלו מו"מ, בהסכמתה ובידיעתה של התובעת, אשר בסופו נחתם ההסכם שהקנה לחלילי אפשרות לבנות על הגג. הסכם זה נחתם לאחר שחלילי הציג לנתבע את יפוי הכוח, התצהיר והערת האזהרה הרשומה לטובתו ולאחר שייצר מצג ברור לפיו הוא הבעלים של חלקת משנה מס' 2.

18. כחלק מאותה תרמית פעלו חלילי והתובעת למחיקת הערת האזהרה שביצעו לאחר השלמת הבניה וזאת במנוגד להגיון המשפטי אשר מכוחו נרשמה מלכתחילה ההערה, שחייב הותרתה על כנה על מנת להבטיח את העברת הזכויות בדירה החדשה, שטרם נרשמה, על שם חלילי.

19. התובעת וחלילי בנו דירה נוספת ששווייה רב בעקבות הסכמת הנתבע, ואין לאפשר להם כעת, לאחר שהנתבע שינה מצבו לרעה, לחזור בהם מהתחייבותם.

ההליכים בתיק-

20. ביום 23.7.15 התקיים דיון הוכחות. במהלכו העידו מטעם התביעה התובעת, עו"ד יוסף שלש והנתבע. לאחר שהתביעה הבהירה כי אין בכוונתה להזמין את חלילי להעיד הלה הוזמן להעיד כעד הגנה.

21. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע בסוגיה.

דיון והכרעה-

22. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה, ולחייב את התובעת בהוצאות הנתבע. הכול כפי שיפורט להלן:

פרשנות המסמכים עליהם חתמה התובעת-

23. אין מחלוקת כי לדירת התובעת הוצמד גג. עם זאת, הצמדת הגג כשלעצמה, לא אפשרה לתובעת לבצע בניה של דירה נוספת, שכן פסיקה רבת שנים קובעת כי העובדה שלדירה בבית משותף הוצמד הגג לא מקנה לבעליו את הזכות לבנות עליו ללא הסכמת יתר בעלי הדירות בבית.

24. בעניין זה יש להפנות לדבריו של כב' הנשיא (בדימוס) מ. שמגר בע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 811, 807 (1980):

"... יש לאבחן בין ההצמדה של חלק מן הרכוש המשותף לדירה מסוימת לבין הרשות לבנות. גם אם יש הסכמה להצמדה, אין פירושו עדיין כי יש בכך גם משום הסכמה של יתר בעלי הדירות לבניה ודרושה בכל מקרה הסכמתם כתנאי לקבלת ההיתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965."

25. וראו גם ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1) 469, 476 (1999):

"נקודת המוצא לדיון בשאלה הראשונה היא, שככלל יש להבחין בין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף לאחת מן הדירות בבית המשותף, לבין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד. הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע, שלבעל הדירה קמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות הבנייה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית..." (ההדגשה שלי י.ל.).

26. וכן ראו גם ע"א 749/76 יוסף נ' בכר, פ"ד לב(3) 617, 621 (1978); א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין – חלק שלישי: בתים משותפים (2001), בעמ' 220.

27. בנסיבות אלו ברי כי לצורך הבניה הנוספת נדרשה הסכמת הנתבע לבנייה זו.

28. מעדות חלילי עלה כי הנתבע סירב בתחילה לתת הסכמה לבניית הדירה הנוספת. לפיכך קיים חלילי מו"מ עם הנתבע במהלכו הציג לו את יפויי הכוח עליו חתמה אימו המייפה כוחו של עו"ד עבד אל רחמן לפעול בעבורה להוצאה לפועל של רצונה לאפשר לבנה לבנות על הגג, וכן הציג בפניו תצהיר בדבר העברה ללא תמורה מהנתובעת לחלילי והציג בפניו נסח רישום מקרקעין המלמד כי בגין עסקה זו נרשמה הערת אזהרה לטובתו על דירת התובעת.

29. בעקבות המו"מ שניהלו חלילי והנתבע נחתם ההסכם המפורט בסעיף 5 לעיל. במועד בו נחתם ההסכם הייתה רשומה בנסח הרישום על בעלותה של התובעת

הערת אזהרה מיום 15.12.11, על פי יפויי כוח בלתי חוזר, לטובת הנתבע. כיום טוענת התובעת כי יפויי הכוח ותצהיר העברה מייפים כוחו של עוה"ד לפעול בשמה להעברת הזכויות בגג בלבד ובדירה שתבנה עליו לחלילי, ומשכך, חלילי שלא היה בעל הזכויות בדירתה לא היה מוסמך להגיע להסכמות עם הנתבע בנוגע לרכוש המשותף. הנתבע מנגד טוען כי הוצג בפניו מצג לפיו הנתבע הוא בעל הזכויות המוסמך להתחייב בשם התובעת.

30. עיון ביפויי הכוח שהיווה בסיס לרישום הערת האזהרה מעלה כי הוא ניתן "בקשר להעברת הזכויות "ללא תמורה" ב-דירת המגורים שתיבנה על הגג- ההצמדה (ו), והידועה בספרי המקרקעין, (חלקה 2/2, בגוש- 11676), ברח' אלנבי מס' 63, בחיפה (להלן- "דירת המגורים")." (הדגשה שלי י.ל.). דהיינו: יפויי הכוח, מחד, קובע כי הוא ניתן בקשר לדירת המגורים שתיבנה על הגג. מאידך, מגדיר יפויי הכוח את "דירת המגורים" כחלקת משנה מס' 2, היא דירת התובעת.

31. בסעיף 3 לתצהיר אשר שימש אף הוא בסיס לרישום הערת האזהרה (להלן: "התצהיר") מצהירה התובעת: "הנני מצהירה שאני בעלת זכות הבעלות בשלמות של דירת מגורים הנמצאת ברח' אלנבי מס' 63, בחיפה, והידועה בספרי המקרקעין כחלקה 2/2 בגוש- 11676 (להלן: "דירת המגורים"). הצהרה זו נתמכת כמובן בנסח רישום המקרקעין, כמפורט לעיל, בו מופיעה התובעת כבעלים של חלקת משנה מס' 2. עינינו הרואות כי הן ביפויי הכוח והן בתצהיר הוגדרה דירתה של התובעת, חלקת משנה מס' 2, כ-"דירת המגורים".

32. בסעיף 4 לתצהיר נקבע: "הנני מעבירה בזאת במתנה וללא תמורה ל- "בני" חלילי ח'טאב הנ"ל, את "הגג המוצמד לדירתי בשטח של 96.73 מ"ר והמסומנת באות (ו), בצבע ירוק" כנ"ל, את כל חלקי וזכויותי המהווים חלקים "בשלמות" בגג הנ"ל."

33. בסעיף 7 לתצהיר נקבע: "תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה להעברת הזכויות ברשויות המוסכמות, ולצורך ביצוע העברת הזכויות בדירת המגורים על-שם "בני" במתנה וללא תמורה." (הדגשה שלי י.ל.).

34. נמצא, אם כן, כי בעוד שבסעיף 4 מצהירה התובעת כי היא מעבירה לחלילי את הזכויות בגג הצמוד לדירתה, הרי שבסעיף 7 מצהירה התובעת כי התצהיר ניתן התמיכה לבקשתה להעביר לחלילי את הזכויות בדירת המגורים שלה (היא חלקת משנה מס' 2).

35. התובעת טענה בפניי כי התכוונה להקנות לחלילי רק את הזכויות בגג, הא ותו לא, ומכאן שחלילי לא היה מוסמך לחתום על ההסכם ולהתחייב בשמה, ואילו הנתבע טען כי באמצעות התצהיר, יפויי הכוח והערת האזהרה הציג לו הנתבע מצג ולפיו הוא רכש מהתובעת את הזכויות בדירה כולה והוא מוסמך להתחייב בשמה בהסכם.

36. עומדת בפנינו, אם כן, שאלת פרשנותם של מסמכים אלו, לאמור- האם התובעת התחייבה בתצהיר וביפויי הכוח להעביר לחלילי את הגג בלבד, כטענתה במסגרת ההליך, את הדירה בלבד או את הגג והדירה גם יחד.
37. לצורך הכרעה בשאלה זו יש לבחון את הסעיפים הרלבנטיים מחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
38. סעיף 13 לחוק המקרקעין קובע את הכלל לפיו לא ניתן לבצע עסקה בחלק מן המקרקעין : "...ואין תוקף לעסקה בחלק מסויים במקרקעין, והכל כשאין בחוק הוראה אחרת."
39. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובע כי חלק שהוצמד לדירה : "בעלי הדירות ושאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן-התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית ... ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד."
40. כפי העולה מהסעיף ניתן להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירה, ובדרך זו הוצמד הגג לדירת התובעת, אך מרגע ביצוע ההצמדה הופך החלק הצמוד, לענייננו הגג, להיות חלק בלתי נפרד מהדירה אליה הוצמד.
41. משמעות הדבר היא כי לא ניתן לבצע עסקאות בהצמדה בלבד במנותק מהדירה. חריג לכך נקבע בסעיף 62(א1) לחוק המקרקעין המאפשר העברת הצמדה בין בעלי דירות באותו בית משותף. וראו בעניין את הדברים שנאמרו בספרו של מ. דויטש, קניין, כרך א' בעמ' 703; וכן בספרו של י. ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף בעמ' 421.
42. אשר על כן לא ניתן לבצע "עסקה" בהצמדה (גג) בלבד במנותק מהדירה. התובעת אינה טוענת כנגד "תקפות" העסקה אותה ביצעה עם בנה, אלא "אך" מבקשת להגביל עסקה זו לגג הבית בלבד, דבר שאינו אפשרי על פי החוק.
43. משמצאתי כי לא תיתכן העברת בעלות לחלילי בגג דירת התובעת במנותק מהדירה אתכבד ואבחן את הוראת סעיף 25 א' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") הדנה באופן פרשנות חוזה.
44. קובע סעיף 25 א' לחוק החוזים, הנזכר לעיל, מספר כללי פרשנות כדלהלן :
- "(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.
- (ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל.
- (ב1) חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.

(ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג
יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים."

45. הכלל הבסיסי בפרשנות חוזים הינו כי הטקסט של החוזה יפורש על פי התכלית המונחת ביסוד החוזה, וכי מתוך מגוון המשמעויות הלשוניות של החוזה יש לבחור באותה משמעות משפטית המגשימה את תכלית החוזה. לשון החוזה היא האמצעי אשר באמצעותו מוגשמת המטרה אותה רצו הצדדים להשיג. ראו בעניין את ספרו של אהרון ברק, **פרשנות במשפט**, כרך רביעי, בעמ' 287 ואילך וכן בעמ' 383 ואילך.

46. כחלק מהחתימה להשגת התכלית האובייקטיבית נקבע בסעיף 25 א'(ב) לחוק החוזים כי בחוזה הניתן לפירושים שונים, יש להעדיף פירוש **המקיים** את החוזה על פני פירוש שלפיו הוא בטל.

47. לנוכח האמור לעיל, מקום שיש לכאורה הוראות סותרות בחוזה (בענייננו נוסח התצהיר למול נוסח ייפוי הכוח והסתירות הקיימות בתוך כל מסמך), יש להעדיף את הפירוש המקיים את החוזה על פני זה שירוקן את החוזה מתוקף חוקי.

48. בהקשר זה נקבעו בע"א 702/80 **גלפשטיין נ' אברהם**, פ"ד לו (4) 113, 119 הדברים הבאים:

"יש לבכר את הפירוש המתקבל על הדעת על הפירוש, שאינו משאיר שום אפשרות לביצוע החוזה לא רק ככתבו וכלשונו אלא גם לפי רוחו... אין לקבל פירוש של החוזה, אשר מביא ליצירת מעגל שוטה, המוציא כל אפשרות לקיים את החוזה או לנקוט צעדים משפטיים במקרה של הפרה על-ידי אי-קיומו."

וברוח דומה הוסיף כב' השופט ד' לויין בע"א 524/83 **קן-תור נ' אלון**, פ"ד מ(2) 556, 533:

"כללי הפרשות הבסיסיים קובעים, כי כאשר נדרשת פרשנות למסמך בכתב וניתן להציע פרשנויות שונות, תנתן למסמך (בענייננו תניות שבחוזים) אותה משמעות אפשרית, המתיישבת עם העיסקה ותנאיה בכללה ומקיימת אותה, ותועדף על כל פרשנות, המרוקנת סעיף שבחוזה מתוכנו."

49. נקודת המוצא בעניין זה היא שקיימת חזקה שתכלית החוזה היא שהוראותיו לא יסתרו אלו את אלו ושהיו ניתנות לקיום. משכך, מבין כמה מובנים שלשון החוזה יכולה לשאת, יש לבכר את אותו מובן המונע סתירה בחוזה ומונע את ביטולו או הפיכתו לחוזה בלתי חוקי. ראו בעניין את דברי כב' הנשיא בדימוס א' ברק בספרו **פרשנות במשפט**, כרך רביעי, פרשנות החוזה בעמ' 589, וראו גם ע"א 226/80 **כאהן נ' מדינת ישראל**, פ"ד לה (3) 463, 471.

50. כאמור, סעיפי חוק המקרקעין, אינם מאפשרים ביצוע עסקאות בהצמדה במנותק מהדירה. משאין מחלוקת כי התובעת מבקשת לקיים את ההסכם עם בנה הרי שברור שיש להעדיף הפרשנות לפיה התצהיר וייפוי כוח יפורשו ככאלו שבאו להקנות לחלילי זכויות בגג הצמוד לדירת התובעת וממילא בדירה עצמה. משכך, ולאור העובדה שיש לבכר פירוש המקיים את התצהיר ואת יפויי הכוח על פני פירוש המבטל אותם, מוצאת אני לפרש את המסמכים ככאלו שבאו להקנות לחלילי זכויות להירשם כבעלים של דירת התובעת והגג הצמוד לה, וזאת על מנת להוציא אל הפועל את הבנייה שתוכננה על הגג. שהרי, כל עוד לא נבנתה הדירה הנוספת על הגג לא ניתן היה, לאור סעיפי חוק המקרקעין, למכור לחלילי את הגג ובוודאי שלא לשעבד אותו במשכנתה. משכך, ועל מנת שזכויותיו של חלילי יובטחו בחר האחרון להחתים את התובעת על מסמכים המעבירים לו את הזכויות בדירה ביחד עם הגג, על מנת שיתאפשר לו לבנות לעצמו את הדירה הנוספת. כפי שיפורט להלן, נאותה התובעת- אמו, לבצע כל פעולה שדרש ממנה חלילי לצורך הגשמת רצונו זה.

51. פרשנות אחרת של ייפוי כוח והתצהיר היו הופכים אותם, כאמור לעיל, למסמכים חסרי נפקות משפטית גם ביחסים שבין חלילי לתובעת והדעת אינה סובלת תוצאה זו.

המצג שהציג חלילי-

52. מעדות הנתבע שוכנעתי כי חלילי הציג בפניו מצג ולפיו הוא רכש את הנכס מאמו. לצורך כך הציג חלילי בפניו את הערת אזהרה שרשם לטובתו, את ייפוי הכוח והתצהיר וטען כי הוא מורשה להתחייב בשמה של התובעת בכל התחייבות הנוגעת למקרקעין (ראו עדותו בעמ' 19 שורות 10-8 וכן בשורות 15-14).

53. חיזוק לעובדה שחלילי ראה עצמו כבעלים של דירת התובעת וכמי שרשאי להתחייב בשמה מצאתי בעדותו של חלילי בפניי. בעדותו בפניי מעד חלילי בלשונו והשיב כי הוא הבעלים של הדירה (דירת אמו- התובעת), טעות אותה ניסה לתקן בחקירתו החוזרת. ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 40-39 :

ש. זאת אומרת אתה הבעלים של הדירה, משכנתה אותה לטובת הלוואה שלך, שאם לא היתה מוחזרת הכל היה הולך לבנק. זה נכון?

ת. כן."

54. זאת ועוד, מעדותו של חלילי עלה כי אמו, התובעת, ידעה על מהלכיו השונים. חלילי עצמו העיד כי: "אני לא עושה שום דבר ללא ידיעתה" (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורות 21-17). משכך, חזקה כי המצג שהציג חלילי לנתבע כי הוא רשאי להירשם כבעלים של הנכס היה מצג משותף שהיה ידוע לתובעת היטב והנ"ל גם הייתה

מודעת "לרווח" שנפל בחלקה בגין הסכם זה – הזכות לבנות על גג הבית הצמוד לדירתה, זכות שלא היתה בידה קודם ההסכם.

55. גם העובדה שהתובעת דרשה מהנתבע לסלק ידו מהרכוש המשותף רק לאחר שסיים בנה לבנות ולא נקטה כנגדו הליכים כל זמן הבניה מלמדת כי התובעת הייתה שותפה למצג.

56. יצוין כי בעקבות המצג וההסכם ניתנה לנתבע רשות לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף. המדובר ברשות שלא ניתנה "חינם" אלא בתמורה. בנסיבות אלו אני מוצאת את הרשות הנ"ל כרשות בלתי הדירה.

החלת עקרון תום הלב-

57. עוד מצאתי לחייב את התובעת בנפקות ההסכם מכוח חובת תום הלב החלה כעקרון על במשפטנו.

58. במקרים מתאימים, מצאו בתי המשפט להחיל את עקרון תום הלב גם על דיני הקניין, ובאמצעותו ליתן מזור לעותר.

59. כב' השופט ברק קבע גם בע"א 579/83 זוננשטיין ואח' נ. אחים גבסו בע"מ קבלני בנין פ"ד מב(2) 278, בעמ' 290:

"עיקרון תום הלב, 'מצודתו פרושה' – כדברי השופט אלון (בע"א 700/81 [8]), בעמ' 742 - 'על כלל המערכת המשפטית בישראל'. אין הוא מוגבל לביצוע חוזה בלבד, ואין הוא מותנה בקיומו של חוזה. אין הוא עוסק אך ב'נבל ברשות החוזה', אלא חל הוא גם לענין 'נבל ברשות החוק' [...] על-כן, כאשר חוק מעניק לאדם יכולת לבצע פעולה משפטית, עליו להפעיל יכולת זו בתום לב..."

60. עיקרון תום הלב בא אף לידי ביטוי בהוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין הקובע:

"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר."

61. ברע"א 6339/97 רוקר נ. סלומון פ"ד נ"ח(1) 199 אושרה ההלכה לפיה:

"עקרון תום-הלב חל בגדריו של חוק המקרקעין. אכן, חוק המקרקעין אינו עומד בפני עצמו. הוא חלק מהחקיקה (האזרחית) שלנו. עקרון תום-הלב, החל על החקיקה (האזרחית) כולה, חל גם עליו." (שם בעמ' 275).

בהמשך פסה"ד קובע כב' הנשיא ברק כי:

"עקרון תום-הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר מתוך הגינות כנדרש על-פי תחושת הצדק של החברה בישראל, מעצם מהותו, עקרון תום-הלב מהווה אמת-מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני-אדם. הקטגוריות של תום-לב

לעולם אינן סגורות; לעולם אינן נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים." (שם בעמ' 279 מול האות ב).

62. חלילי התבקש בעדותו להסביר מדוע מחק את הערת האזהרה שהייתה רשומה לטובתו לאחר שהשלים את בניית דירתו. לא הייתה לו כל תשובה מניחה את הדעת מדוע עשה כן. להלן עדותו בעניין, בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 29-34:

"ש. אבל אתה אחרי שעברת לגור בבית דאגת למחוק את הערת האזהרה בדבר הייפוי כח בדבר ההצהרה של אמא שלך, בדבר כל זכות שלך. נכון? אתה הלכת לעו"ד עם אמא נכון?
ת. נכון.

ש. למה מחקת את הערת האזהרה?
ת. אין לי תשובה

ש. התכוונת לוותר על הזכויות שלך בבית שבנית?
ת. זה בינתיים הכל של אמא שלי.

ש. אני מנסה להיכנס לראש שלך למה מחקת את הערת האזהרה?
ת. אני לא יודע. יש לי משכנתא על הדירה, אני לא יודע, יכול להיות שביקשו ממני מבנק טפחות למחוק."

וראו גם עדותו בעניין בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 5-8.

63. סבורני, כי זהו המקרה עליו נכון להחיל את עקרון תום הלב, באופן שיחול על ניהול המו"מ שהתקיים, על נסיבות החתימה על ההסכם ועל התועלת שהפיקו חלילי והתובעת מאותו הסכם. לאורו של עקרון תום הלב, יש לבחון את ניסיונו של חלילי ועצימת עיניה של התובעת, שנועדו לאפשר לחלילי להתחמק מההתחייבות שנטל על עצמו כנגד הסכמתו כי יבנו דירה על הגג. במקרה זה סעד של "השבה" יהא בלתי צודק בנסיבות העניין, ולכן יש לכוף על התובעת ובנה את ההתחייבות אותה נטלו במשותף בתמורה לזכות לבנות על גג הבית הצמוד לדירתם.

64. לאחר ששמעתי את עדות התובעת אני סבורה כי המדובר בתכנית שתוכננה היטב מראש ע"י חלילי על מנת "לחלץ" מהנתבע הסכמה ולאחר מכן להתכחש להתחייבות שניתנה.

65. מעדותה של התובעת ניכר כי היא הייתה כלי בידי בנה, לא התעניינה בפעולות המשפטיות שביצעה ושיתפה עימו באופן מלא פעולה. כל רצונה של התובעת היה: "רציתי שהוא ייבנה על ידי ויישאר לידי לא יותר." וכך מעידה התובעת בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 14-18:

"ש. איך עשית את העברת הגג?

ת. אני לא הלכתי לעו"ד או חתמתי על מסמכים. הבן שלי הלך ועשה את הכל.

ש. חתמת על מסמכים מסוימים?

ת. לא.

ש. חתמת שאת מעבירה לו?

ת. על הגג.

ש. על מה חתמת?

ת. לא חתמתי."

66. התובעת לא הייתה מעורבת באופן פיזי בהסכם שנחתם בין חלילי לנתבע ובהתאמה גם לא הייתה מעורבת בהגשת תביעה זו. התובעת נשאלה בעדותה מי יזם את הגשת התביעה נגד הנתבע והשיבה שאין לה מושג: "אני רק יודעת שאני פה" (ראו עמ' 6 לפרוטוקול שורות 39-40 וההמשך בעמ' 7). הרושם הכללי שנותר הוא כי התובעת היא עושת דברו של בנה. באשר יאמר היא תלך אחריו.

67. חלילי לעומתה העיד כי הוא הבין כי נדרשת לו חתימת הנתבע לצורך הוצאה לפועל של בניית הדירה על הגג, וכי חתימתו על גבי ההסכם והתשריט הנלווה לו ניתנו לאחר שבחן אותם מס' פעמים, ולא במחטף, ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 25-28 וכן שורות 29-32. חלילי גם אישר בעדותו כי הוא זה אשר יזם את הגשת התביעה דנא, הוא ולא התובעת אני סבורה כי בנסיבות אלו אין ליתן את הסעד שנתבקש שמא ייצא חוטא נשכר.

68. ראויה לציטוט עדותו של חלילי בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 4-8 אשר יכולה לשפוך אור נוסף על אופן התנהלותו ותחכום תוכניתו:

"ש. זאת אומרת כשחתמת על ההסכם נ/1 הזה לא היית מוסמך לחתום על זה.
ת. נכון.
ש. גם כשחתמת על נ/2 לא היית מוסמך לחתום על זה?
ת. חתמתי על המסמך. אני לא יודע אם אני מוסמך או לא מוסמך. לא חשבתי על זה. חתמתי כדי לקדם את העניינים של היתר הבנייה. זה מה שהיה בראש שלי.
ש. אבל בנ/1 כתבת שאתה מוותר על רכוש משותף האם היית מוסמך לוותר?
ת. לא הייתי מוסמך. אבל רק עכשיו אני יודע את זה."

69. בהמשך עדותו מאשר חלילי שהוא זה שיזם את מחיקת הערת האזהרה ולא התובעת, אך אינו זוכר מדוע (ראו בעמ' 13 שורות 5-6). העד אישר כי כל המהלכים והפעולות שנעשו היו יוזמה שלו (ראו בעמ' 16 שורות 1-4). עוד אישר העד כי בחותמו על ההסכם ידע על מה הוא חותם ועל אלו שטחים הוא מוותר (ראו עדותו בעמ' 13 שורות 32-34).

70. התנהגותו זו של חלילי, אשר מחק את הערת האזהרה אשר נרשמה לטובתו ונועדה להגן על זכויותיו מראה עד כמה מחושב היה חלילי, וכיצד תכנן מראש את הדרך לחמוק מהתחייבותו לנתבע. חלילי כנראה סבר כי מחיקת הערת האזהרה תעלים כל עקבות אשר קושרים אותו לדירת התובעת, מה שיקל על התובעת לכפור בכוחו של ההסכם לחייב.

71. הנתבע העיד כי פעל על סמך השכנות והנאמנות שהייתה בין הצדדים להליך והסתמך על המצג שהציג לו חלילי ולפיו רכש את הבעלות בדירת התובעת. לדבריו לאחר שחלילי סיים לבנות "הוא בא ואמר לי שאני יכול להכין מהמסכמים מטוס" (ראו עדותו בעמ' 19 שורות 14-16).

72. אין להלום שהתובעת, אשר נתנה לחלילי יד חופשית לעשות בדירתה כראות עיניה וחתמה על כל מסמך אשר נדרש להוציא לפועל את רצונו לבנות, תסתתר מאחורי ייפוי הכוח והתצהיר אשר ניתנים לפירושים שונים. אין לאפשר לאותו חלילי אשר הביא את הנתבע להאמין שהוא הבעלים של הדירה, להתכחש למצג אותו יצר וליזום את הגשת תביעה זו.

73. מכל הטעמים שפורטו לעיל נכון לטעמי לפרש את ייפוי הכוח והתצהיר ככאלו בהם התחייבה התובעת להעביר לחלילי את הזכויות בדירה בצוותא חדא עם הגג, וכפועל יוצא חלילי היה רשאי להתחייב בהסכם בשמו ובשם התובעת.

74. למען לא יהא הנייר חסר אציון כי לו הייתי מגיעה למסקנה כי ייפוי הכוח והתצהיר לא הסמיכו את חלילי לפעול ולהתחייב בשמה של התובעת, אזי, היה חל על מסכת העובדות כאן סעיף 6 (ב) לחוק השליחות, תשכ"ה-1965 אשר קובע כדלהלן:

"לא ידע הצד השלישי בשעת הפעולה שהשלוח פועל ללא הרשאה או בחריגה מהרשאתו, הברירה בידו, כל עוד לא נודע לו על אישור הפעולה, לראות את השלוח כבעל דברו או לחזור בו מן הפעולה ולתבוע מן השלוח את נזקו."

75. הנה כי כן, אם ייקבע כי השלוח- חלילי פעל ללא הרשאתה של התובעת או בחריגה מהרשאתה, אזי, מורנו הסעיף כי הצד השלישי-הנתבע רשאי לחזור בו מהפעולה, קרי מההסכם, ותוצאת מהלך זה תביא לביטול הסכמתו של הנתבע לבנייה שביצע חלילי, מה שיחייב את חלילי להרוס את הדירה שבנה.

סוף דבר-

76. אני דוחה את התביעה להורות לנתבע לסלק ידו מחצר הבית המשותף.

77. לא מצאתי להורות לנתבע להרוס או לסלק מבנים שבנה ברכוש המשותף מהטעם שסעד זה אמנם התבקש בכתב התביעה, אך נזנח כליל בהמשך. הוא הדין לגבי הבקשה לפירוק שיתוף בחצר, משמצאתי כי ההסכם בתוקף ולנתבע קיימת הזכות לעשיית שימוש ייחודי בחצר הבית, אין עוד מקום להידרש לבקשה לפירוק שיתוף בחצר – מה גם שסעד זה אינו בתחום סמכותי העניינית.

78. אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבע החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (22.2.15) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יב' באלול התשע"ה (27.8.15).
העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין